

《【문제3】 재소의 금지에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 재소의 금지의 요건, 적용 범위, 효과

I. 문제의 제기

- 재소금지란 본안에 대한 중국판결이 있는 뒤에 소를 취하한 사람은 같은 소를 제기하지 못한다는 원칙을 의미한다.(민사소송법 제267조 제2항) 이는 소취하의 자유를 악용하여 법원을 농락하거나 상대방을 괴롭히는 행위를 방지하고, 국가 재판권의 권위를 유지하며 사법 자원의 낭비를 막는 데 그 목적이 있다. 재소금지는 기판력과 달리 소송계속 중의 행위인 소취하에 기해 발생하므로 실체적 권리 자체를 소멸시키는 것은 아니지만, 소송법상 적법한 소 제기 권능을 박탈하는 효과를 가진다. 이하에서는 재소금지의 요건으로서 주관적 요건, 객관적 요건, 소취하의 시기적 요건 및 재소의 동일성 여부와 그 효과에 대하여 설명한다.

II. 재소금지의 요건

1. 주관적 요건(당사자의 동일성)

(1) 원칙

- 재소금지는 소를 취하한 원고와 그 피고 사이에 적용된다. 따라서 원고나 피고가 다른 경우에는 원칙적으로 재소금지가 적용되지 않는다.

(2) 예외

- 당사자가 동일하지 않더라도 민사소송법 제218조에 따른 기판력의 주관적 범위가 미치는 승계인 등에게는 재소금지의 효력이 미친다는 것이 판례의 태도이다. 또한 채권자대위소송에서 채무자가 소송계속 사실을 알았음에도 원고인 채권자가 중국판결 후 소를 취하였다면 채무자에게도 재소금지의 효력이 미친다.

2. 객관적 요건(소송물의 동일성)

(1) 동일한 소의 의미

- 재소금지에서 말하는 동일한 소란 전소와 후소의 당사자, 소송물 및 권리보호이익이 동일한 경우를 말한다. 소송법상 경제적 이익이 같더라도 소송물이 다르면 재소금지에 해당하지 않는다.

(2) 신청의 형태

- 전소가 이행의 소였으나 후소가 확인의 소인 경우처럼 소의 형태가 다르더라도 그 기초가 되는 권리관계가 동일하고 재소금지의 취지에 반한다면 동일한 소로 취급될 수 있다.

3. 시기적 요건(중국판결 후의 소취하)

(1) 중국판결의 존재

- 본안에 대한 중국판결이 선고된 이후여야 한다. 소간각하나 소송판결 후의 소취하는 재판권의 낭비가 없으므로 재소금지가 적용되지 않는다. 1심 판결 후뿐만 아니라 항소심 판결 선고 후 소를 취하한 경우도 포함된다.

(2) 소취하의 유효성

- 소취하가 유효하게 성립해야 한다. 만약 소취하가 무효이거나 취소된 경우에는 재소금지의 문제가 발생하지 않는다.

4. 권리보호이익의 동일성(새로운 사정의 유무)

- 후소를 제기할 정당한 사유나 새로운 사정이 발생한 경우에는 예외적으로 재소금지가 적용되지 않는다. 전소 취하 당시에는 예상할 수 없었던 사정변경이 생겨 다시 소를 제기할 필요가 있는 경우가 이에 해당한다.

III. 재소금지의 적용 범위

1. 반소의 경우

- 피고가 본안에 대한 중국판결 후 반소를 취하한 경우에도 재소금지의 원칙이 적용되어 다시 반소를 제기하거나 별도로 청구할 수 없다.

2. 소의 변경

- 소의 변경 중 추가적 변경은 기존의 소를 유지하면서 새로운 청구를 보태는 것이므로 취하의 문제가 없으나, 교환적 변경은 구 청구의 취하와 신 청구의 제기가 결합된 것이므로 중국판결 후 교환적 변경을 하여 구 청구를 취하하게 되면 재소금지의 적용을 받는다.

IV. 재소금지의 효과

1. 소송법상 효과

- 재소금지의 요건에 해당하면 후소는 부적법하게 되며, 법원은 직권으로 이를 조사하여 판결로써 소를 각하하여야 한다. 이는 전속관할과 유사한 공익적 성격을 가지므로 당사자의 합의로도 재소금지의 효과를 배제할 수 없다.

2. 실체법상 효과

- 재소금지는 소송법상의 제재일 뿐이므로, 원고의 실체법상 권리 자체를 소멸시키는 것은 아니다. 따라서 원고는 소송 외에서 권리를 행사하거나 상계의 청구 등으로 대항하는 것은 가능하다.

V. 결론

- 재소금지의 원칙은 법원의 중국판결이 있는 후 소를 취하하여 판결을 무효화시킨 자에게 부과하는 강력한 소송법상 제재이다. 이는 소송 경제를 도모하고 사법 제도의 신뢰를 유지하기 위한 필수적인 장치이다. 그러나 당사자의 재판을 받을 권리를 본질적으로 제한하는 측면이 있으므로, 판례는 승계인에 대한 효력이나 새로운 사정변경이 있는 경우 등 구체적 사안에서 재소금지의 범위를 합리적으로 해석하여 운영하고 있다. 실무적으로는 중국판결 후의 소취하가 가져올 불이익을 당사자에게 충분히 고지하여 신중한 절차 선택을 유도하는 것이 필요하다.